

1500159-27.2022.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... pugnou pela desclassificação do delito de tráfico para o crime de posse de drogas para consumo próprio ou, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 220-231).

A defesa de Fábio Magalhães dos Santos requereu a parcial procedência da ação penal para o fim de desclassificar-se o crime de tráfico de drogas para co delito do art. 28 da Lei 11.343/06. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500159-27.2022.8.26.0573 - lauda

TERMO DE CONCLUSÃO

São Manuel, 16 de agosto de 2022.

O Escr.,

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500159-27.2022.8.26.0573

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

CLEBER ROBERTO DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou FÁBIO MAGALHÃES DOS SANTOS e CLEBER ROBERTO DE LIMA como incurso no artigo 33, "caput"; e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 06h00min, concomitantemente, nas Ruas Antônio Malossi, 420, Cohab IV e Amélia Rodrigues, 100, São Geraldo, nesta cidade e comarca de São Manuel, FABIO MAGALHÃES DOS SANTOS e CLEBER ROBERTO DE LIMA guardavam 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido total de 4,93 gramas e 02 (duas) porções maiores, também de cocaína, com peso líquido total de 1.424,65 gramas, todas individualmente embaladas, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, bem como 01 (uma) balança de precisão, 40 (quarenta) saquinhos plásticos para embalar drogas e R\$ 2.409,00 (dois mil, quatrocentos e nove reais) em espécie.

Segundo a denúncia, "foi montada uma operação policial, a fim de cumprir um mandando de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Manuel, em relação a indivíduos que estariam vendendo grande quantidade de drogas

no município. Assim, os agentes de segurança se deslocaram, concomitantemente, até os endereços acima referidos, os quais são das residências dos denunciados. Após chegarem à rua Antônio Malossi, 420, Cohab IV, residência do denunciado Fábio, os policiais adentraram na mesma e com ajuda de cão farejador, passaram a diligenciar no intuito de encontrar substâncias entorpecentes. Neste contexto, lograram êxito em encontrar 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido total de 1.424,65 gramas, uma encontrada no interior da residência e outra encontrada no interior do automóvel do denunciado. Concomitantemente, parte da equipe que participou da operação se deslocou até à rua Amélia Rodrigues, 100, São Geraldo, residência do denunciado Cleber. No interior da residência encontraram 01 (uma) porção de cocaína embalada pronta para mercancia, com peso líquido total de 4,93 gramas, além de 01 (uma) balança de precisão, 40 (quarenta) saquinhos plásticos para embalar drogas, e R\$ 2.409,00 (dois mil, quatrocentos e nove reais) em espécie. De pronto o denunciado Fábio assumiu que guardava os entorpecentes para o denunciado Cleber, em troca de R\$ 200,00 (duzentos reais) por semana, afirmou ainda, que Cleber reiteradamente buscava as drogas, bem como levava outras quantidades para ele guardar. Cleber, sem ter informação sobre as diligências na residência de seu comparsa Fábio, negou o tráfico, e disse que a porção de cocaína apreendida em sua residência, destinava-se a consumo próprio. Diante do cenário, bem como pelo fato de que, há algum tempo, os denunciados vinham sendo monitorados, em razão da prática do delito de tráfico de entorpecentes e, portanto, eram conhecidos dos meios policiais, foi realizada a prisão em flagrante de ambos. Assim, as circunstâncias em que ocorreram as prisões (cumprimento de mandado, flagrante, seguida pela apreensão da balança de precisão, caderno, dinheiro em espécie e drogas), somadas a natureza e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, e, ainda as palavras dos policiais, são circunstâncias que evidenciam a mercancia ilícita exercida pelos denunciados, que se associaram para obter êxito na prática delituosa”.

Antecedentes criminais de Cleber Roberto de Lima (fls 47-48), e Fábio Magalhães dos Santos (fls. 50-51).

Folha de Antecedentes de Cleber Roberto de Lima (fl. 49), e de Fábio Magalhães dos Santos (fls. 52).

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 82.

Decisão recebendo a denúncia em 29 de julho de 2022. às fls. 184.

Notificados, os réu apresentaram defesa prévia: Cleber Roberto de Lima às fls. 148-151; e Fábio Magalhães dos Santos às fls. 176-178.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem com, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da exordial acusatória e a defesa técnica dos acusados requereu prazo para apresentação de memoriais escritos (fl. 213-218).

A defesa do réu Cleber Roberto de Lima, em sede preliminar, suscitou a nulidade da denúncia quanto ao crime de associação criminosa, eis que não houve efetiva descrição dos fatos aptos a tipificarem o referido crime. No mérito, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito de tráfico para o crime de posse de drogas para consumo próprio ou, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 220-231).

A defesa de Fábio Magalhães dos Santos requereu a parcial procedência da ação penal para o fim de desclassificar-se o crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em meio aberto (fls. 251-261).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da preliminar de inépcia da denúncia quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06

A denúncia genérica é aquela cuja imputação é contaminada por situação de grave deficiência na narração do fato atribuído ao(s) agente(s). A imputação, na denúncia genérica, não contém os elementos mínimos de sua identificação como crime, como às

vezes ocorre com a simples alusão aos elementos do tipo penal abstrato. Por isso, a denúncia genérica sofre com a pecha da criptoimputação (imputação truncada, criptografada), por consagrar um sistema processual kafkiano, no qual o denunciado não tem ideia do que se defende.

No caso dos autos, o Ministério Público narrou de maneira clara e escorreita os atos que entende se tratarem de crime de associação criminosa, permitindo aos acusados conhecerem a imputação e elaborar sua estratégia de defesa, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da denúncia, eis que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"Apelações. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINAR. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. A denúncia reclama apenas a plausibilidade da imputação, aferida à luz dos dados colhidos na fase inquisitorial, cenário presente na espécie. Preliminar rejeitada." (TJ-SP 0001034-70.2018.8.26.0360, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 14/03/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019)

Do pedido de conversão do julgamento em diligência para fins de realização de exame de insanidade mental do acusado Cleber

Não obstante tenha o réu alegado, em seu interrogatório judicial, ser usuário de drogas, é certo que, na oportunidade em que foi inquirido, ele não apresentou qualquer indicativo que revelasse estar sua capacidade cognitiva comprometida em razão do uso de entorpecentes.

Pelo contrário, o réu se revelou lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura, informando, ainda, trabalhar na empresa Holambra e de forma autônoma, possuindo, ainda, pretensões políticas na comarca.

Não se deve olvidar que a alegação de ser o réu viciado em drogas ilícitas não se confunde com a dependência àquela substância. O ilustre doutrinador Luiz Flávio Gomes preleciona que o vício "...consiste no hábito ou consumo persistente da pessoa consumir droga (consumo irresistível), sem repercussão na sua capacidade de entendimento (imputável, portanto). Já a dependência pode alcançar o nível de doença mental ou retirar do agente a capacidade de tomar decisões, de entender e querer, ou seja, a sua autodeterminação (inimputável) quando sob o efeito da droga..." (in "Lei de Drogas comentada: artigo por artigo: Lei 11.343, de 23.08.2006" Alice Bianchini. [et al.] Luiz Flávio Gomes, coordenação 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 215/216).

Cumprir registrar o posicionamento do Col. STF sobre o tema, no sentido de que "...a perícia é necessária: a) quando houver dúvida a respeito do poder de autodeterminação do acusado; b) quando houver evidência de que a conduta foi realizada em virtude de dependência do uso de substância entorpecente..." (HC nº 70.268 1ª T. rel. Min. Celso de Mello - in DJU de 17-06-1994 pág. 15708); complementando que "...o reconhecimento feito pelo próprio acusado de que é viciado não basta para que o Juiz ordene a realização do exame de dependência toxicológica, pois a própria Lei nº 6.368/76 não define em quais hipóteses será obrigatória a perícia, desde que justifique fundamentadamente suas razões..." (STF, HC 76.581-4-MG1ª T., j. 18-08-1998, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJU de 13-11-1998, RT 761/523).

A imputabilidade é a regra, sendo exceção a inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Não bastasse, como dito, não se mostra presente comportamento de impulso ou circunstâncias da forma de execução que indicassem de qualquer forma estivesse o acusado privado da capacidade de querer e de se determinar.

Não há indício algum de dependência toxicológica importante, sobretudo à época dos fatos, não constituindo elemento idôneo autorizador da instauração do incidente o mero fato de o réu se declarar usuário de substância entorpecente, especialmente à míngua dos elementos de prova.

Nesse sentido:

"INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. Simples alegação da condição de usuário ou dependente químico que não constitui elemento suficiente para justificar a realização da perícia toxicológica, que exige elementos concretos que ponham em xeque as capacidades intelectual e volitiva do

acusado. Precedente. Circunstâncias dos autos, ademais, que revelam discernimento do acusado quanto ao caráter criminoso dos fatos e determinação de acordo com esse entendimento." (TJ-SP - APR: 15011018620198260210 SP 1501101-86.2019.8.26.0210, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 06/07/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/07/2020)

"NULIDADE DO FEITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

Indeferimento devidamente fundamentado, já que desnecessária a prova, além de seu caráter impertinente. Magistrado, destinatário da prova, não constatou qualquer indício de comprometimento da higidez mental do apelante, que pudesse comprometer sua imputabilidade. Denunciado relatou em juízo ter sido internado cerca de um ano antes e, desde sua liberação, não buscou tratamento para a alegada dependência químico-toxicológica. Pedido indeferido." (TJ-SP - APR: 15000397120218260232 SP 1500039-71.2021.8.26.0232, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 22/11/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/11/2021)

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A ação penal é parcialmente procedente.

Do crime de tráfico ilícito de entorpecentes

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 25-28), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23-24); pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 112-114), bem como pela prova oral colhida na instrução.

A autoria restou incontroversa.

A testemunha Cláudio Aparecido Leme, policial civil, disse que foi realizada uma operação conjunta das polícias civil e militar; que cumpriu mandado de busca na casa do Fábio, onde foi apreendida uma pedra de cocaína de 1,5kg; que Fábio disse que estava guardando para o "Clebinho"; que havia denúncias no sentido de que Cleber vendia drogas em conjunto com outra pessoa; não sabe dizer quando ocorreu a associação, mas que já ocorria há meses; Fábio guardava a droga e ganhava uma porcentagem na venda; não sabe se Cleber confessou os fatos; que Fábio confessou o crime em vídeo gravado pela polícia civil; não recorda dos réus serem envolvidos em crimes de tráfico; não participou de campanas no local; não sabe se outros policiais fizeram campanas no local; sabe que Cleber é usuário de drogas, pois a esposa do réu contou ao depoente; não sabe há quanto tempo o réu Cleber é dependente de crime de drogas; não sabe se houve registro das denúncias anônimas; não recorda quem fez a gravação; não sabe se foram garantidos o direito ao silêncio na gravação; não conhecia o réu Fábio; não foi encontrado dinheiro com Fábio; que o réu Fábio disse que guardava a droga para o "Clebinho" e ganhava R\$ 200,00 por semana; que a esposa de Fábio foi à delegacia, mas não sabe como chegou no local. A testemunha Marcelo Alexandre Ribeiro Ferreira, policial civil, disse que o setor de inteligência apurou que Cleber vendia cocaína na cidade, sendo que seria uma das drogas mais puras; que Cleber guardava pouca droga em sua residência, pois apenas armazenava o que seria vendido no dia; que havia uma "casa forte" onde a droga estava armazenada; que na casa de Cleber foi encontrada uma porção de cocaína; embalagem para embalar a droga; uma balança de precisão e quantia em dinheiro; que estava investigando os réus há oito meses; que trabalham com informações e "in loco"; que visualizou Cleber fazendo a venda de drogas em campanas; que descobriram que Fábio guardava a droga para Cleber ao acompanhar seguidas idas de Cleber até a residência do corréu para pegar drogas; que Fábio teria dito que guardava a droga em troca de poder cheirar o entorpecente; que o dinheiro estava em notas variadas e que Cleber não soube justificar a procedência do dinheiro; que o dinheiro estava guardado junto com a droga em um guarda-roupa; que não atuou no flagrante na casa do Cleber; que sabe que Cleber trabalha na empresa Holambra e vende churrasquinho; não sabe se Cleber é dependente de drogas; não recorda de a esposa do Fábio estava na delegacia.

A testemunha Carlos Alberto Nepomuceno, policial militar, disse que foi feita uma operação conjunta entre a polícia militar e a polícia civil para busca e apreensão de drogas em São Manuel; que sua equipe se dirigiu até a casa de Clebinho; soube

que em outra residência em que havia sido cumprido mandado de busca havia informação de que o réu Fábio disse que guardava drogas para Cleber; que localizou uma porção de drogas e a quantia de aproximadamente R\$ 2.500,00 na residência do réu; que um policial civil localizou invólucros para embalar a droga e uma balança de residência no quintal da casa; que o réu e sua esposa não souberam explicar a origem do dinheiro; não conhecia Cleber, pois faz patrulhamento em Botucatu; que o delegado disse que Cleber é dono de uma boca de tráfico em São Manuel; que a droga estava em um guarda-roupa e o dinheiro estava em outro cômodo; que foi o delegado quem deu voz de prisão para o réu Cleber; que réu negou a traficância e disse que era usuário.

A testemunha Marcos Roberto Leonardo, policial militar, disse que participou de uma operação integrada das policiais civil e militar na cidade de São Manuel para cumprir mandados de busca e apreensão na casa dos réus; que cumpriu o mandado para a casa do Fábio, sendo que lá foi encontrado 1,5kg de cocaína; que Fábio disse que apenas guardava a droga para Cleber e recebia dinheiro em troca; que o réu indicou um dos tijolos de droga em seu quarto e outro tijolo foi encontrado com ajuda de cão farejador no veículo de Fábio; que posteriormente foi até a casa do Cleber, mas já tinha havido a vistoria pelos policiais que lá estavam; não recorda se a esposa foi levada para a delegacia de polícia; que sabe que houve um vídeo de confissão realizado pela polícia civil; que esposa e os filhos de Fábio estava na casa; que a esposa do réu foi contida durante a abordagem.

A testemunha de defesa Evandro Roberto da Costa disse que conhece o réu Cleber há 25 anos; que estudou com o réu e hoje é seu vizinho; que Cleber é dependente de drogas; que sempre via Cleber drogado no bairro; que Cleber é dependente de drogas há cerca de 20 anos; que Cleber foi internado para tratamento de vício de drogas; que o réu Cleber foi internado mais de uma vez; nunca soube que o réu traficava.

A testemunha de defesa Glaucia Aparecida dos Santos Araújo disse que conhece o réu Cleber desde que nasceu e nunca soube que ele era traficante; que sabia que o réu era usuário de droga e já foi internado em uma clínica de reabilitação; que o réu usa drogas há mais de vinte anos.

A testemunha de defesa Gabriel Franco de Freitas disse que conhece Fábio há 10 anos e mora cerca de dois quarteirões da sua residência; que o réu Fábio é trabalhador e um bom pai; que não sabia do envolvimento do réu com o tráfico de drogas; que o réu trabalhava na empresa Holambra; que o réu tem dois filhos e um deles possui um deficiência; que Fábio acompanhava o filho no tratamento.

Interrogado, o réu Cléber Roberto de Lima confessou que estava com a droga. Disse que é dependente químico e que comprou a droga para seu próprio uso; que estava em recuperação e teve uma recaída, razão pela qual comprou a droga; que trabalha registrado na Holambra e vendendo espetinho; que deixava a droga com Fábio para não cheirar tudo de uma vez; que comprou grande quantidade para não ser visto em biqueiras; negou ter envolvimento com o tráfico; que tem pretensões políticas na cidade e não queria ser visto comprando drogas, por isso comprou grande quantidade; que tinha renda mensal de R\$ 5.000,00; que comprou a droga por R\$ 12.000,00; que comprou a droga em Bauru e que ela foi entregue por um moto táxi; é casado; tem uma filha e uma enteada; trabalhava na Holambra há um ano e quatro meses; na Holambra ganhava R\$ 2.800,00; que já usou crack e na época recaiu por causa da cocaína; nunca foi preso, nem foi processado; na delegacia estava acompanhado de advogado; que mudou a versão porque sua esposa estava na delegacia e ficou com medo de sua esposa ser presa; que foi forçado a dar a versão dos policiais; que estava nervoso, pois a primeira vez que foi preso; que apenas trabalhava junto com Fábio e deixava a droga com ele porque tinha necessidade compulsiva de usar drogas; que foi a primeira vez que combinou deixar drogas com o réu Fábio; que o dinheiro era proveniente do seu trabalho, fruto do trabalho registrado e da venda de espetinhos; que sabia o valor que estava em sua casa; que o dinheiro estava na bolsa da sua esposa; que os saquinhos eram para embalar os molhos dos espetinhos e a balança era para pesar a carne; que desconhece o caderno; que dependente há 24 anos e foi internado seis vezes; que a droga era para uso seu e de Fábio; que é diabético e não há tratamento adequado no CDP.

Interrogado, o réu Fábio Magalhães dos Santos, negou os fatos. Disse que a droga

foi encontrada na sua casa, mas que era para consumo do Cleber; que o não era pago para ficar com a droga, pois usava junto; que deu a versão em vídeo sob ameaça de sua esposa ser presa e seus filhos serem encaminhados ao Conselho Tutelar; é casado, tem dois filhos e trabalhava na Holambra; que tem 28 anos e é primário; não teve passagem por Fundação Casa; um de seus filhos é autista e necessita de seus cuidados para ir à APAE; que somente guardou a droga para Clebinho e usava a droga com ele; nunca presenciou a droga com Clebinho, nem viu ele vendendo; que sua abordagem foi feita pela polícia civil; que a gravação foi feita em sua casa; que sua esposa estava com os policiais no quintal; que os réus disseram que iam prender sua mulher.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito: "São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017).

Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que os réus praticaram o delito em voga, basta ver a expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder dos Fébio (uma porção de cocaína, com peso líquido de 4,93 gramas e duas porções maiores com peso líquido 1.424,65 gramas), bem como a quantia de R\$ 2.409,00 encontrada com o réu Cleber, tudo a evidenciar a mercancia ilícita. Saliento que condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia, tratando-se de tipo misto alternativo, cuja conduta do réu se ajustou à modalidade "trazer consigo".

O delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151).

O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Consoante já se decidiu, "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp. nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190).

Nessa perspectiva, podemos acrescentar a jurisprudência do STJ: "Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.

Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EDcl no HC 446151/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).

No caso específico dos autos, os réus foram flagrados na posse de vultosa quantidade de drogas durante o cumprimento simultâneo de mandados de busca e apreensão expedidos por esta Vara e cumpridos na residência de cada um dos réus por

equipes diversas das polícias civil e militar.

Foram apreendidas com o réu Fábio duas porções de cocaína com peso líquido total de 1.424,65 gramas; já na residência de Cleber localizou-se uma porção de cocaína, uma balança de precisão, saquinhos plásticos e a quantia de R\$ 2.409,00, não havendo dúvidas, portanto, da existência de concurso entre os agentes objetivando vender drogas na comarca.

A versão apresentada pelos réus no sentido de que Cleber adquiriu a droga para seu próprio consumo em grande quantidade na cidade de Bauru para não ser visto em pontos de venda de droga com frequência, pois é conhecido na cidade por trabalhar com a venda de churrasquinhos e possui pretensões políticas, não se sustenta, eis que mostra-se alheia à prova dos autos, já que, além das drogas, foram apreendidos valores, uma balança de precisão e saquinhos para embalar as drogas, descaracterizando-se, assim, a posse para consumo.

Ademais, em que pese os réus possuírem empregos fixos na empresa Holambra e o réu Cleber trabalhar também vendendo churrasquinhos, a expressiva quantidade de drogas revela o ânimo da traficância, já que, ainda que empregados, os réus não lograram êxito em comprovar de forma efetiva a capacidade econômica para adquirir a droga que, segundo o próprio réu Cleber, teria custado R\$ 12.000,00.

Assim, observo ser segura a prova de que os réus, efetivamente, adquiriram a droga com eles apreendidas objetivando a mercancia espúria, sendo, pois, de rigor, a procedência da ação penal em relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Do crime de associação para o tráfico de drogas

O crime de associação para o tráfico de drogas resta plenamente caracterizado quando duas ou mais pessoas associam-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/06.

No entanto, a locução "reiteradamente ou não", prevista no caput do art. 35, pode levar o intérprete à errônea conclusão segundo a qual a mera reunião de duas pessoas, sem vínculo associativo (estabilidade), para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, já seria suficiente para caracterizar a associação para o tráfico.

De fato, essa situação configura concurso eventual de pessoas (coautoria ou participação), e não o crime de concurso necessário do art. 35 da Lei 11.343/2006 que, inegavelmente, reclama a affectio criminis societatis.

No art. 35 da Lei de Drogas, portanto, é imprescindível o liame associativo, revestido de estabilidade e permanência entre seus integrantes.

Em síntese, é consabido que, para a caracterização do delito de associação para o narcotráfico, faz-se imprescindível "o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006."

Nesse sentido:

"Apelação. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência.

Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de inépcia da denúncia, que satisfaz os requisitos estampados no artigo 41 do CPP. MÉRITO. 1.

Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelos delitos previstos no artigo 33 "caput", da Lei nº 11.343/05 e artigo 329 do Código Penal. 2. O delito estatuído no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes. Panorama não configurado na hipótese. Absolvição decretada em relação a esta segunda acusação. 3. Incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bastando, para tanto, atentar-se exclusivamente ao critério espacial, não se exigindo que a atividade esteja visando especificamente os usuários do estabelecimento. Precedentes do STJ e do STF. 4. Não aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. 5

Penas que comportam redimensionamento. 6. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 15009803820188260616 SP 1500980-38.2018.8.26.0616, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 13/06/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2020)

No caso dos autos, em que pese os indícios de que os réus se associaram com a

finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, a investigação policial apenas se baseou em denúncias anônimas e informações da inteligência da polícia civil que não foram documentadas, sendo que os investigadores ouvidos em juízo relataram a existência de investigações e campanhas, porém tais diligências não foram formalizadas em documentos.

Saliente-se, por oportuno, que a existência de petrechos para pesar e embalar as drogas indicam a existência do tráfico, contudo, no sentir deste Juízo, para que se configure o crime de associação para o tráfico é imprescindível aprofundada investigação no sentido de apurar o efetivo ânimo dos agentes em associarem-se com estabilidade e permanência para praticar crimes de tráfico de entorpecentes, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, ausentes informações concretas acerca da suposta associação para o tráfico firmada entre os réus, eis que não há nos autos fotos, filmagens ou quaisquer outros registros acerca das campanhas realizadas pela polícia, tampouco foram requeridas quebras de sigilo telefônico ou telemático aptas a demonstrar a estabilidade e permanência da suposta associação descrita na denúncia, a absolvição dos réus, neste ponto, é medida de rigor.

Desta feita, autoria e materialidade comprovadas, passo à dosimetria da pena, atento ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a culpabilidade dos réus, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não é acentuada a ponto de merecer exasperação da pena-base; os réus não registram maus antecedentes, pois não possui condenações com trânsito em julgado, conforme se observa da folha de antecedentes das fls. 107-111 (Súmula 444, STJ); não há registros nos autos quanto a conduta social e a personalidade do agente; motivos normais ao tipo; o delito foi praticado em circunstâncias normais ao tipo; a conduta social não foi apurada nos autos; as consequências do delito são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do tipo penal.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as utilizará (HC 351.325/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018), postergo a análise de tais circunstâncias para a terceira fase da dosimetria.

Fixo a pena base no mínimo legal para ambos os réus.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado tendo em vista a expressiva quantidade de drogas encontradas em depósito com os réus e o concurso de agentes, ainda que eventual, evidenciam a dedicação dos réus à mercancia ilícita de cocaína na comarca, o que impede o reconhecimento da figura privilegiada.

Em caso semelhante, o TJ-SP:

"APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Recurso ministerial que visa o afastamento da figura do tráfico privilegiado e a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso. 2. Dosimetria que comporta reparos. Quantidade de drogas apreendidas que se mostrou excessiva. Aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/10. Atenuante da confissão espontânea. Retorno da pena ao patamar mínimo. Apreensão de expressiva quantidade de cocaína. Circunstâncias que apontam para a convergência de indícios de envolvimento do acusado em organização criminosa e de dedicação às atividades ilícitas. Impossibilidade de configuração do tráfico privilegiado o qual pressupõe cenário de pequena e/ou eventual traficância. Precedentes. 3. Fixação do regime prisional

semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível." (TJ-SP - APR: 15025203320198260537 SP 1502520-33.2019.8.26.0537, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 05/04/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2022)

Fixo a pena definitiva para ambos os réus em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP)

Considerando-se a quantidade de pena imposta, ausentes os efeitos da reincidência, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2, alínea "b", o Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP) e da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP)

Diante do montante de pena aplicada, incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.

Do Direito de Recorrer em Liberdade/Prisão Preventiva (artigo 387, §1º, do CPP)

Os réus respondem ao processo preso desde 28 de maio de 2022, sendo que o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, visto que a reprimenda aplicada nesta sentença é mais benéfica que a prisão cautelar determinada na decisão das fls. 80-82.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares." (TJ-SP - HC: 20378927420218260000 SP 2037892-74.2021.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021)

Dessa forma, revogo a prisão cautelar e concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, desde que cumpridos as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates ou qualquer outro estabelecimento de má reputação; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde residem por lapso superior a 08(oito) dias, sem autorização do Juízo; c) recolher-se em seu domicílio das 22:00 às 06:00 da manhã, exceto se estiverem trabalhando; d) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades e, ainda, comunicar o Juízo, qualquer mudança de endereço que ocorra.

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FÁBIO MAGALHÃES DOS SANTOS e CLEBER ROBERTO DE LIMA, para:

A) CONDENAR os réus como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário-mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP, desde a prática do delito, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 387 e seguintes do Código de Processo Penal;

B) ABSOLVER os réus da imputação relativa ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Revogo a prisão cautelar, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitivo;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens

apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;
Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contra prova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Nada mais sendo requerido e efetivada as providências acima, remetam-se ao arquivo, depois das anotações e comunicações.

Sentença registrada digitalmente.

Publique-se. Intimem-se.

São Manuel, 22 de agosto de 2022.

JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA